

1509573-33.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... (com o réu), que se destinavam mesmo ao tráfico. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de venda para a configuração do tráfico.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1509573-33.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509573-33.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 12807080 - 03º D.P. AMERICANA, 2190433

- DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 121/20/346 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2190433/2020 -

DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE PAULO MARÇAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

GABRIEL HENRIQUE PAULO MARÇAL foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 04 de agosto de 2020, por volta de 16h34, na Rua Maranhão, 382, bairro Balneário Riviera, Condomínio Vida Nova I, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, 51 porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso de 7,48 gramas (sete gramas e quarenta oito centigramas), além de R\$ 90,00, drogas prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2021 (fls. 143/144) e o réu foi citado (fls. 154).

Na instrução foram inquiridas três testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 189/193).

A Defesa reclama pena mínima, pela primariedade, com reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Não se dedicava a atividade criminosa e nem integrava organização criminosa. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime brando e recurso em liberdade (fls. 197/198).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase administrativa permaneceu em silêncio.

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em Juízo, nada ousou alegar.

A prova oral o incriminou, contudo.

Gisele Cristina Serrante de Souza, testemunha, explicou que não possuía relação de parentesco com o acusado. Na data, lavava roupas, a porta de seu apartamento estava aberta. Gabriel entrou correndo e as Guardas entraram atrás dele. O acusado foi detido dentro da sua casa. Os Guardas Municipais localizaram alguns pacotes plásticos que ele havia dispensado no imóvel. Morava no Bloco 03, apartamento 14, do andar térreo.

A testemunha guarda municipal Nelson Ribeiro, recordou-se de que realizavam operação pela área do Condomínio Vida Nova I e II, visavam combater o tráfico de drogas no local. Ao acessarem o Condomínio Vida Nova II, Gabriel saiu correndo e entrou em um apartamento. Correram atrás dele, ingressaram no apartamento que estava aberto. O acusado jogou algo no chão da sala e correu até o banheiro. No momento em que entrou no banheiro, Gabriel havia dado descarga e estava saindo. Localizaram uma sacola plástica no vaso, ela não desceu com o acionamento da descarga. Em seu interior, havia três kits, contendo 15 eppendorfes de cocaína cada, totalizando 45 eppendorfes de cocaína. Posteriormente, identificaram que foram dispensadas mais substâncias na sala (06 pinos de cocaína), totalizando 51 eppendorfs de cocaína, todas com embalagens idênticas. Durante a revista, encontraram no bolso do acusado a quantia de R\$ 90,00. Gabriel estava próximo

dessa moradia. Ao avistar as viaturas, ele correu até o interior do apartamento. Acreditava que a porta do apartamento estivesse aberta, pois houve um princípio de pânico, as pessoas que estavam dentro do imóvel gritaram, não sabiam o que estava acontecendo. O acusado foi direto para o banheiro. A proprietária do imóvel, Gisele, alegou que conhecia Gabriel e que ele não morava ali. Confirmou que o réu invadiu o apartamento. A testemunha também foi conduzida até a Delegacia. Indagado, Gabriel negou a propriedade dos entorpecentes, no entanto o viram disparando a descarga. A sacola não desceu no vaso devido ao grande volume.

Roque Prado Moitinho, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que a ROMU realizava a 'Operação Saturação' nas proximidades do Condomínio Vida Nova I e II para coibir crimes, devido ao alto índice de tráfico naquele local. Avistaram alguns suspeitos correndo e os abordaram. Ao empreender fuga, Gabriel entrou em uma residência. O acusado dispensou algo na sala e foi até o banheiro. Flagraram o réu tentando dispensar dentro do vaso sanitário certa quantidade de drogas (três kits). Gabriel tentava efetuar o descarte de uma sacola. Na entrada da sala, onde o acusado jogou os objetos, encontraram seis porções de entorpecentes, que aparentavam ser cocaína. A droga encontrada na sala era igual a do banheiro. Gabriel portava dinheiro no bolso de sua vestimenta, cuja quantia não soube precisar.

Como se vê, os guardas municipais realizavam a "Operação Saturação", em local conhecido como ponto de venda de drogas. Avistaram o acusado no interior do referido condomínio e este, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu suspeitosa fuga. Invadiu o apartamento da testemunha Gisele e arremessou, no chão da sala, um saco contendo 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos de cor azul.

Em seguida, Gabriel foi até o banheiro e despejou no vaso sanitário mais 03 (três) sacos, contendo em cada um 15 (quinze) porções da mesma droga (totalizando 45 porções), as quais estavam acondicionadas de forma idêntica àquelas encontradas na sala do imóvel.

Durante a revista, os guardas localizaram R\$90,00 nas vestes de Gabriel, sem que o réu, prontamente ou a qualquer tempo, justificasse a lícita procedência.

A quantidade da droga, embalada individualmente e juntada em kit's, propícios para a venda, a par da fuga e dispensa dos entorpecentes, a par da quantidade-nocividade da droga e forma de embalagem, acompanhada de numerário (com o réu), que se destinavam mesmo ao tráfico. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de venda para a configuração do tráfico.

Na doutrina:

"Nota-se facilmente que o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, isto é, possui várias condutas típicas separadas pela conjunção alternativa "ou". Em razão disso, a pluralidade de condutas envolvendo o mesmo objeto material constitui crime único. Exemplo: adquirir, transportar, guardar e depois vender a mesma substância entorpecente. Nesse caso, há um só crime, porque as diversas condutas são fases sucessivas de um mesmo ilícito. Os crimes de ação múltipla são também chamados de crimes de conteúdo variado ou de tipo misto alternativo. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, é suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo desnecessária a realização de atos de venda do entorpecente." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, 2020, pág.87, Legislação Penal esquematizada).

E na jurisprudência:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O fato de o réu também ser usuário de drogas, evidentemente, não exonera a conduta, antes tem por absorvido, o porte de drogas para uso, pelo tráfico ora reconhecido. Note-se que o réu sequer ousou apresentar versão nas vezes em que interrogado - inquérito/juízo.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 31/33 e 62/64), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 65/67).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é primário. A quantidade de drogas era normal para o tipo de infração, tráfico. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Mantenho inalterada a pena base, fixada no mínimo.

Na terceira fase, pela não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de metade, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida (51 porções de cocaína).

Possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecido o tráfico privilegiado e a somatória final da pena, com estipulação do regime aberto para o caso de revogação.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, o regime inicial aberto, analisada a detida conduta dos autos, é de ser imposto ao condenado, primário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar GABRIEL HENRIQUE PAULO MARÇAL, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e par. 4º, da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo. Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto a destruição da droga.

Condeno o réu nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, na medida em que constituiu advogada após a nomeação de defensor, pelo convênio OAB SP - Defensoria (fls. 44), sem comprovação de que fosse hipossuficiente.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 24 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA